

1512551-64.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Margot Chrysostomo Corrêa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/09/2022

... CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1512551-64.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1512551-64.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2144092/2022 - DEL.SEC.2ª SUL, 25216386 - DEL.SEC.2ª SUL, 2144092 - DEL.SEC.2ª SUL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAIQUE DE MORAES BRAGA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot Chrysostomo Corrêa

Vistos.

KAIQUE DE MORAES BRAGA e GABRIEL DE MORAES BRAGA, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incursos no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06. Isso porque, na data de 27 de maio de 2022, por volta das 06h15min, na residência localizada na Rua Ângelo Rojas, nº 247, no bairro de Jaraguá, nesta cidade e comarca de São Paulo, KAIQUE tinha em depósito e guardava, para fins de venda e entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

I) 14 (quatorze) invólucros plásticos encerrando planta arbustiva com aproximadamente 85 cm de comprimento e constituída por raiz, caule, folíolos, inflorescência e frutos, pesando, aproximadamente, 3,8kg (três quilos e oitocentos gramas) da substância Tetrahydrocannabinol (THC), vulgarmente conhecida como

maconha; e

II) 122 (cento e oito) invólucros plásticos encerrando porção de fragmentos vegetais ressequidos, constituídos de folhas, folíolos, inflorescências, caules e frutos, pesando aproximadamente 174,9g (cento e setenta e quatro gramas e nove decigramas) da substância Tetrahydrocannabinol (THC), vulgarmente conhecida como maconha.

Consta ainda que na data de 27 de maio de 2022, por volta das 06h15min, na residência localizada na Avenida Pinheirinho D'Água, nº 237, no bairro de Jaraguá, nesta cidade e comarca de São Paulo, GABRIEL tinha em depósito e guardava, para fins de venda e entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

III) 57 (cinquenta e sete) invólucros plásticos encerrando porção de fragmentos vegetais ressequidos, constituídos de folhas, folíolos, inflorescências, caules e frutos, pesando aproximadamente 73,1g (setenta e três gramas e uma decigrama) da substância Tetrahydrocannabinol (THC), vulgarmente conhecida como maconha.

Narra a denúncia que KAÍQUE e GABRIEL, de forma livre e consciente, com vistas à distribuição a terceiros, guardavam e tinham de depósito em suas residências mudas, sementes e derivados de "maconha", mantendo estrutura para cultivo da planta relacionada à substância e acessórios voltados à mesma finalidade.

Em cumprimento ao mandado judicial de busca e apreensão expedido nos autos de número 1517019-23.2022.8.26.0050, para apuração de envolvimento de GABRIEL em delito de roubo ocorrido no dia 29 de outubro de 2021, por volta das 08h50, na Avenida dos Bandeirantes, altura do numeral 1747, Vila Olímpia, São Paulo/SP, policiais civis diligenciaram nos dois endereços acima mencionados.

Na residência situada na Rua Ângelo Rojas, nº 247, Jaraguá, São Paulo/SP.

A D. Autoridade Policial, Dr. Luís Fernando Pompermayer Ayres e o policial civil, Bolival Oliveira de Souza, se dirigiram ao local e foram recebidos por KAÍQUE, que autorizou a entrada na residência mediante apresentação do mandado judicial e prontamente admitiu a posse de maconha.

No interior da residência de dois cômodos, os policiais lograram êxito em encontrar uma estrutura similar com duas "estufas" de cultivo de maconha, onde havia 14 plantas. Os policiais ainda encontraram sementes para o plantio, diversos insumos para o cultivo, como terra e fertilizantes, uma caixa que acondicionada porções da droga para "secagem", e uma balança de precisão, além de 108 (cento e oito) porções de maconha encontradas no interior de potes e sacos plásticos prontas para a venda, tratando-se de drogas de alta qualidade.

Segundo apurado, cada planta gera cerca de 120g de maconha para consumo, cujo valor de venda seria de R\$ 60,00 por grama. Os policiais ainda apreenderam celular do indiciado e cartões de crédito, de modo que, em consulta ao teor das comunicações mantidas no referido aparelho, KAÍQUE negociava a venda dos entorpecentes a terceiros. Diante destas circunstâncias, o indiciado afirmou que cultivava para consumo próprio, mas comercializava o excedente.

Na residência situada na Avenida Pinheirinho D'Água, nº 237, Jaraguá, São Paulo/SP. Os policiais civis, Fabrício Souza Leão e Patrik José Nunes de Souza Filho, se dirigiram até este local, um terreno que possui duas casas. Os policiais civis foram recebidos por Juliana Simões de Moraes, que se identificou como genitora dos denunciados, que autorizou a entrada na residência mediante apresentação do mandado judicial. Juliana esclareceu residir em um dos imóveis com seu companheiro, ao passo que GABRIEL residia em outro imóvel, situado nos fundos do terreno, na companhia de sua avó, Lizolete Maria de Moura. Em buscas efetuadas na residência do indiciado, os policiais encontraram 57 (cinquenta e sete) porções de maconha, separadas individualmente para venda, além de embalagens plásticas, de modo que as porções de entorpecentes encontradas eram idênticas daquelas apreendidas na residência onde estava KAÍQUE. GABRIEL confirmou a propriedade da droga, que era destinada para consumo próprio e comercializava o excedente. Diante desta situação, todos os entorpecentes e itens foram apreendidos e os indiciados foram levados à Delegacia na companhia dos policiais.

Interrogado na presença de seu advogado, KAÍQUE informou que recebeu os policiais, autorizou a entrada no imóvel e disse possuir os entorpecentes para consumo próprio, mas negou a venda a terceiros. KAÍQUE recebe auxílio de seu irmão GABRIEL para o cultivo da droga. A droga encontrada em poder dele era oriunda de sua produção. Em relação aos diálogos encontrados em seu celular, esclarece que apenas mencionou o valor que cobraria pela droga se fosse vendê-la. No entanto, as vendas nunca foram concretizadas, esclarecendo que adquire as sementes para o plantio em perfis diversos do Instagram. No tocante aos crimes patrimoniais investigados, afirmou não possuir ligação com nenhum crime.

Interrogado na presença de seu advogado, GABRIEL afirmou que foram encontrados 04 (quatro) potes de maconha destinada para consumo próprio para um mês, sem intenção de vender para terceiros. Presta pequenos auxílios diários neste cultivo, mas ele é feito em sua maior parte por KAIQUE. Desconhece se o seu irmão comercializa as drogas que produz, de modo que as sementes e demais insumos são adquiridos pelo Instagram. Em relação aos delitos patrimoniais, é titular de duas contas bancárias e a emprestou-a, algumas vezes, para recebimento de valores.

Oferecida a denúncia de fls. 01/06, foi ela recebida por despacho no dia 18 de julho de 2022 (fls. 191/195). Consequentemente, os acusados foram citados (fls. 180; 182), vindo aos autos, no prazo legal, a defesa prévia (fls. 185/187). Não sendo supridos os requisitos para a absolvição sumária, agendou-se uma audiência de instrução e julgamento para o dia 01 de setembro de 2022 (fls. 191/195).

Durante a instrução de causa foram ouvidas 4 testemunhas arroladas pelo Ministério Público, duas testemunhas arroladas pela Defesa e os réus foram interrogados ao final.

Encerrada a instrução criminal o Ministério Público requereu a condenação de ambos nos termos da denúncia, regime fechado, sem possibilidade de aplicação de benefício.

Defesa requer, para Gabriel, a desclassificação, para uso de droga.

Subsidiariamente, requer a aplicação do privilégio. Quanto a Kaique, requer a aplicação do tráfico privilegiado, regime aberto recurso em liberdade.

Encontram-se nos autos, ainda, o boletim de ocorrência alusivo aos fatos (fls. 17/23); o auto de prisão em flagrante (fls. 07); o auto de exibição e apreensão (fls. 27/28); o laudo pericial (fls. 29/34 e 144/148); bem como as folhas de antecedentes dos acusados (fls. 80/82; 83/85; 114/115; 118/119).

É o relatório.

Fundamento e decido.

É parcialmente procedente a ação penal porque, ao cabo da instrução criminal restou perfeitamente delineada a autoria e a materialidade do crime tipificado pelo artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 em relação a Kaique. Contudo, em relação a Gabriel, entendo que a desclassificação nos termos propugnados pela Defesa é de rigor.

Com efeito, a materialidade delitiva foi aferida pelo teor do auto de exibição e apreensão (fls. 27/28) e dos laudos de constatação provisória (fls. 29/34), bem como pelo laudo toxicológico definitivo de substância entorpecente (fls. 233/236), com resultados positivos para TETRAHIDOCANNABINOL (THC).

Em primeiro lugar, passo a analisar a situação do corréu Gabriel.

No caso dos autos, os policiais estavam em posse de um mandado de busca e apreensão, expedido em uma investigação relacionada a pessoas ligadas a quadrilhas de Pix. Os policiais fariam incursões em dois endereços então foram duas equipes. Em um dos endereços onde os policiais cumpriram o mandado de busca era a casa de Gabriel. Os policiais estavam atrás de armas e objetos ligados a crimes de roubo e extorsão, relacionados a quadrilha do pix pois havia alguns indícios do envolvimento dele nesse tipo de delito. Ocorre que, embora nada relacionado a crimes contra o patrimônio tenha sido localizado, os policiais acabaram por encontrar cerca de 73g de substância entorpecente conhecida por maconha. A droga se encontrava dentro do seu armário, em potes de vidro.

Restou claro que os policiais não fizeram campana e não havia qualquer

desconfiança, denúncia ou investigação de tráfico em relação aos acusados. Assim, a localização do entorpecente surpreendeu os policiais porque esse não era o objetivo da diligência. O entorpecente localizado com o Gabriel não estava embalado embora devidamente separado. Não localizaram dinheiro, embora tenham localizado algumas embalagens plásticas. No dia de hoje Gabriel reconheceu a propriedade do entorpecente e disse que era para uso próprio e que aquela droga lhe havia sido dada por seu irmão e seria usada por ele durante todo mês. Reconhece que é viciado em maconha, isso desde os 14 anos de idade mas negou tráfico.

A versão de Gabriel é verossímil e não pode ser desprezada. Isso porque, com exceção do entorpecente apreendido em sua residência, o qual não se encontrava embalado para comércio, a quantidade de droga apreendida em poder dele, cerca de 73,1g, por si só não autoriza a conclusão de que ele estava envolvido no tráfico. Não há certeza sobre esta atividade já que não há outros elementos que autorizem essa conclusão, inclusive quanto aos depoimentos dos policiais que, em momento algum, declararam que ele reconheceu o tráfico. Ele residia com a avó e a genitora. Não houve qualquer menção a movimentação típica de tráfico no local.

Importa ressaltar que Kaique e Gabriel são irmãos e moram próximos. Portanto, o fato de Gabriel visitar o irmão não pode ser conclusivo quanto a eventual coparticipação deste no cultivo das plantas ilícitas ou até venda de drogas.

Afinal, nada mais natural que um irmão visite o outro.

Assim, a meu ver, entendo que a desclassificação para uso é de rigor sendo o caso da aplicação do princípio in dubio pro reo.

Naturalmente que a questão relacionada ao pix, caso ele tenha envolvimento, deverá ser objeto de outra ação penal e essa suspeita em nada pode alterar a conclusão deste juízo já que não há relação alguma entre os delitos.

Em segundo lugar, passo a analisar a situação do corréu Kaique.

Já em relação a Kaique, a situação é diversa na medida em que, na casa dele, os policiais que cumpriram o mandado de busca encontraram 14 (quatorze) invólucros plásticos contendo plantas arbustivas com aproximadamente 85 cm de comprimento e constituída por raiz, caule, folículos, inflorescência e frutos, pesando, aproximadamente, 3,8kg (três quilos e oitocentos gramas) da substância Tetrahydrocannabinol (THC), vulgarmente conhecida como maconha e 122 (cento e vinte e dois) invólucros plásticos encerrando porção de fragmentos vegetais ressequidos, constituídos de folhas, folículos, inflorescências, caules e frutos, pesando aproximadamente 174,9g (cento e setenta e quatro gramas e nove decigramas) da substância Tetrahydrocannabinol (THC).

Anoto que em juízo, ele confessou que o cultivo da planta tinha como objetivo sua própria recreação e, eventualmente, reconheceu ter vendido entorpecente a terceiros.

Também em juízo, quatro policiais civis foram ouvidos. Dois deles, inclusive um Delegado de Polícia, participaram da diligência executada na casa de Kaique e os outros dois executaram a diligência na casa de Gabriel.

Passo a transcrever as oitivas produzidas sob o crivo do contraditório.

Dr. Luis, Autoridade Policial que participou do cumprimento do mandado na casa de Kaique reconheceu os dois de uma ocorrência relacionada ao tráfico de drogas. A época dos fatos, era delegado titular do CERCO - DECAP e estava no combate a determinados crimes, principalmente roubos de celular com quebra de vidros e depois utilização do celular para desvio de dinheiro. A partir da investigação dos beneficiários dos depósitos, chegaram em um indivíduo chamado Gabriel (que não é o réu) que havia sido beneficiado por um depósito em dinheiro. Esse indivíduo informou que Gabriel (réu) teria pedido a ele a conta emprestada para depósito do roubo. Conseguiu o endereço de Gabriel e chegou a dois endereços. Expedidos os mandados de busca a estes dois endereços, o depoente participou da diligência praticada na rua Ângelo Rojas, 247 e a outra equipe na Avenida Pinheirinho D'Água, nº 237, endereços próximos. O depoente foi recebido por Kaique. Era por volta das 6 da manhã. Ele abriu a porta e já avisou que tinha maconha em casa. Até aí tudo bem. Contudo, perceberam que havia um laboratório de maconha, duas estufas, 14 pés de maconha e todos os insumos para a produção dessa maconha e algumas embalagens para

comercialização. Indagado, ele disse que fazia a plantação para consumo próprio. No decorrer da conversa, ele informou que com cada pé de maconha seria possível a produção de 120 gramas de entorpecente para uso e como era de boa qualidade, cada grama valeria cerca de 60 reais. A situação não se coadunava com uso próprio. No celular, mediante ordem judicial, pode ver que ele fazia negociação com a maconha. Em seguida ele reconheceu que aquilo que ele não consumia, vendia. A outra equipe se deparou com Gabriel. Lá encontraram cerca de 50 porções, idênticas as que estavam na casa de Kaique. Encontrou, na casa de Kaique, mais de 100 porções já separadas, não se recorda se embaladas. Kaique, na presença do advogado, admitiu a participação dele na quadrilha do pix e que Gabriel também fazia isso. Declinaram o nome da pessoa que estava acima deles e disse quem era o superior deles. Formalmente, eles disseram que a maconha era para uso próprio. Havia uma balança de precisão e isso tem certeza. No mesmo terreno da casa de Kaique havia várias outras residências. A casa de Kaique era uma casa simples, sala onde já encontrou uma estufa e caixas de papelão onde ele utilizava para secar o entorpecente. Em outro cômodo outra estufa. Ele disse que adquirira as sementes pelo Instagram. Na casa dele havia muitas pulseiras e outros objetos relacionados a artesanato. Ainda na residência, leu no celular mensagens onde mencionava o tipo de maconha que ele produzia, ele falava o valor da porção e combinava a entrega em estações do metro mas não se recorda quais. Não se recorda de mensagens trocadas após possíveis vendas. Logo após essa apreensão se removeu para o interior a pedido. As porções de maconha localizadas na casa de Gabriel eram idênticas as que foram encontradas na casa de Kaique. Não esteve na casa de Gabriel. No interrogatório dele na delegacia ele disse que auxiliava Kaique. Não se recorda se o nome Kaique constava na representação. Fabrício, investigador, fez campana nos dois endereços como não participou dessa diligência, não sabe se havia movimentação de tráfico de droga. Não é possível dizer que ali era uma produção profissional de um grande traficante mas pelas informações do próprio Kaique, a conta chega a R\$ 100.000,00 pelo que sabe, em menos de um mês, a planta está pronta para a colheita e consumo. Acredita que não houve apreensão de cadernos de anotações. Com Kaique encontrou R\$ 70,00. No momento da confissão ainda na casa de Kaique, somente havia o réu e a equipe policial.

Policial Bolival reconheceu os acusados. Os acusados são irmãos. Foi designado para cumprimento de mandado de busca e apreensão para verificação de quadrilha de pix e participou da operação realizada na residência de Kaique. Ele nos atendeu e pareceu assustado. Informado dos fatos, ele abriu a porta e já na casa sentiu um forte odor de drogas. Na residência, de cara, encontrou na sala da casa dele um pote com flores de maconha. A casa era pequena, de dois cômodos, e lá encontrou duas estufas. Uma já estava pronta. Esse tipo de maconha não vem prensada. É a própria flor. Acredita que havia uns 15 pés de maconha. Não se recorda se havia material de embalagem. Se recorda de uma balança. Em nenhum momento ele declarou que era para venda. Ele disse que era usuário e de fato havia vários petrechos para uso. Não teve acesso as mensagens de celular dele. Não se recorda se ele chegou a comentar o valor do grama do entorpecente. Não se recorda se ele afirmou quanto cada pé de maconha fornecia em termos de quantidade de entorpecente. Não teve essa conversa com ele. Não participou da investigação, mas chegou a ir no local para fotografar. Não percebeu movimentação de tráfico de drogas. Ele morava só,. Havia muita maconha, tanto no quarto, como na sala. Acha que ele faz alguma coisa de artes, acha que ele produz algum tipo de arte. Classifica a situação como intermediária, nem profissional e nem amador. Dinheiro não tinha. O caderno já não se recorda. O policial Fabrício recordou-se do cumprimento de um mandado de busca e apreensão relacionado a crime de roubo onde um dos indiciados teria sido beneficiado com transação de pix. Montaram uma equipe e o alvo, a princípio era Gabriel. Foi na casa de Gabriel. Na casa dele não encontrou armas ou coisas do gênero mas recorda-se que várias porções de maconha foram localizadas com ele. Lembra de alguns potes de vidro interior do qual estavam as "buchas" de maconha mas não lembra se estavam embaladas em papel filme. Foi apurado que ele frequentava a casa do irmão. Foi feito campana. Ele frequentava a residência mas não é possível dizer que ele dormia lá. Não se recorda se algum deles chegou a falar. Tinha muita maconha. Com Gabriel

tinham porções prontas e com o irmão dele, além dos pés, havia porções prontas também. Na casa de Gabriel somente localizou entorpecente. Não encontrou caderno de anotação ou valores. O celular foi encaminhado ao IC e não se recorda de ter visto nada relacionado a tráfico.

Por fim, o policial Patrick reconheceu os dois. Foram cumprir mandado de busca e a equipe do depoente participou da incursão na rua Pinheirinho. Foram recebidos pela mãe e Gabriel morava na casa do fundo com a avó. Na casa da avó ele encontrou cerca de 50 a 60 porções de maconha, do tipo skunk, de teor mais elevado de THC. Saindo da casa dele, dirigiu-se a casa do irmão dele e lá encontrou uma estufa, um ambiente todo preparado para produzir a maconha turbinada. Chegou a apreender as coisas que estavam lá. Pode afirmar que a maconha encontrada com Gabriel era proveniente da plantação de Kaique. Era a mesma maconha. Não teve acesso ao celular dele. Recorda-se que havia tesoura para fracionar as flores. Não lembra se houve apreensão de anotações ou coisas do tipo. Recorda-se que ele explicou como fazia, como plantava, quanto valia. Ele disse que o valor do grama dessa droga era elevado, 50, 60, até 90 reais. Era uma estrutura muito bem feita. A quantidade apreendida e a quantidade de material existente indicava que seria impossível para consumo próprio. Quase 20 pés de maconha. Na casa de Gabriel só localizou maconha já fracionada. Estava fracionada para uma possível venda. Embalada não. Não era uma residência sofisticada mas não era pobre, refere-se a casa de Gabriel. O cultivo é profissional. Estufas, certa quantidade de luz, nutrientes, sementes diferentes, controle de temperatura. Não considera artesanal.

Duas testemunhas de defesa foram ouvidas, no caso a avó e a mãe dos acusados, vejamos.

Lizotele, avó de Gabriel disse que ele mora com ela. Ele trabalha na prefeitura. Estava presente no dia que ele foi preso. No quarto dele foi encontrada droga. Nunca foi na casa de Kaique. Não é de estar indo na casa de ninguém. Não sabe de nada que foi encontrado lá. Não ouviu nada sobre confissão de que ele comercializava drogas. Não sabia ao certo o que era aquilo. Sabe que ele é usuário. Não costumava entrar no quarto dele.

Juliana é mãe de Gabriel e Kaique. Gabriel mora com a informante e Kaique na casa do pai dele. Acompanhou a prisão de Gabriel. Ele foi preso por conta da maconha que ele fuma. Tem conhecimento que ele fuma maconha. Ele trabalha na prefeitura como fiscal. Kaique mora sozinho na casa que pertence pai. Uns quinze dias antes esteve na casa de Kaique, e não viu estufa nem plantas lá. Acompanhou a prisão de Gabriel e ele em momento algum confessou que era traficante.

Gabriel, interrogado, declarou que tem 25 anos de idade. Trabalha como fiscal da prefeitura, há dois anos. Trabalha terceirizado. É inspetor de obras. Nunca foi preso anteriormente. Que saiba, não responde a outro processo. É dependente de maconha e a droga era para uso próprio. O entorpecente lhe foi dado pelo irmão. Era o suficiente para passar o mês. O entorpecente estava conservado em um pacote anti mofo. Pelo que o irmão fala, a droga era para uso próprio. Não confessou em momento algum que estava vendendo a droga. Não frequentava bocas de fumo. Não ajudava o irmão no cultivo. Não sabe o valor específico da droga. Usa uns 10 cigarros por dia. Usa umas duas gramas em cada cigarro.

Kaique tem 22 anos de idade. Trabalha para um micro empreendedor fazendo peças para que estas possam expor joias, tipo bustos, mãos com papelão, cola, tecido. Mora sozinho na residência do pai. Não tem filhos. Quanto ao cultivo, era para uso recreativo. Aprendeu a cultivar, cultivo artesanal. Chegou a vender. Estava fazendo esse cultivo há um ano e meio. A maconha não era prensada. Há um risco da planta morrer. Fuma de 10 a 15 baseados por dia. Não sabe quantas gramas precisa para fazer um baseado. Nunca teve intuito de ganhar dinheiro. Acredita que uma grama de seu produto valia cerca de R\$ 100,00 reais Gabriel não tem relação alguma com o cultivo. Apenas deu a maconha para ele. A mãe do interrogando viu as estufas mas não quis dizer em juízo.

Pois bem.

Diante da prova colhida, entendo que, de fato, em relação a Gabriel não é possível a condenação por tráfico de drogas pelos motivos já expostos.

Já em relação a Kaique a questão é oposta.

Isto porque, além de sua confissão, os policiais que participaram da diligência deixaram claro que a casa era um local de cultivo de maconha, o que era feito com dedicação e competência, tanto que as fotografias demonstram os cuidados despendidos e a saúde das plantas apreendidas, fls. 35,36 e 39.

A autoridade policial chegou a declinar ter lido mensagens no celular do acusado as quais faziam menção a negociação do entorpecente.

Embora essas mensagens não constem nos autos, é visível a seriedade com a qual a autoridade policial prestou seu depoimento. Não há porque se desconfiar de suas palavras.

Todos os policiais foram uníssonos quanto a quantidade de entorpecente - plantas e insumos relacionados ao cultivo e entorpecente já pronto para o consumo - apreendidos na casa de Kaique.

Os depoimentos dos policiais foram sinceros e harmônicos. Resta claro que foram imparciais em suas oitivas.

Aliás é sabido que no processo penal por tráfico normalmente a prova acusatória consubstancia-se em depoimentos de policiais, civis ou militares, que efetivam a apreensão da droga. E presume-se regular a atuação de agentes públicos investidos no cargo para segurança de todos, pois seria paradoxal que o Estado atribuisse a uma pessoa a execução do ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas desmerecesse sua palavra.

É o raciocínio que mais se coaduna com a realidade das coisas, aplicado na jurisprudência em geral, tanto no Superior Tribunal de Justiça (Resp 151.150-SC, Rel.Min. José Dantas, j. 7.4.98) como no Supremo Tribunal Federal (HC 74.608-0-SP, Rel.Min Celso de Mello, j.18.2.97; HC 76.381-5-SP, Rel. Min Carlos Velloso, j. 16.6.98; HC87.662-PE, Rel. Min Carlos Britto. J.5.9.06).

Nesse sentido ainda:

"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, poder dever de ofício, da repressão penal - O depoimento testemunhal do agente policial somente perderá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar- tal como ocorre com as demais testemunhas- que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência" (HC 73.518-5 SP, Rel. Min. Celso de Mello, j.26.3.96).

De outra parte, Kaique confessou que chegou a vender o entorpecente que cultivava. E isso é bem óbvio porque não seria possível que ele consumisse todo o entorpecente produzido e muito menos que descartava o excedente.

Portanto, em relação a ele, a condenação por tráfico e de rigor.

Contudo, entendo que é possível a concessão do privilégio.

Em primeiro lugar, o entorpecente apreendido não é considerado de alto poder destrutivo.

Além do mais, a meu ver que as plantas apreendidas, com peso de 3,8kg, quantidade que causa impacto, não podem ser consideradas como produtos prontos para a venda a terceiros.

O que efetivamente estava pronto para venda era um total de 174,9g, quantidade que, a meu ver, autoriza a concessão do benefício.

Com efeito, Kaique é primário e não ostenta antecedentes. Não há prova alguma que ele esteja envolvido com organizações criminosas. É ainda muito jovem e resta claro que também era usuário de entorpecente, tanto que o policial Bolival, um dos que fez a incursão na residência dele, confirmou que havia vários petrechos relacionados ao uso da maconha.

Outro ponto relevante, a balança apreendida na casa de Kaique, conforme consta no laudo de fls. 170, estava "impregnada de resquícios de substância de cor esbranquiçada, apresentou funcionamento no momento dos exames"

De fato, Kaique confirmou que utilizava a balança para pesar os insumos que utilizava nas plantas e não para pesar quantidade para venda. Disse a verdade.

Daí porque, entendo que ele é merecedor do privilégio.

Feitas essas considerações, passo a dosar a pena

1) GABRIEL:

Em relação a Gabriel, nos termos do artigo 28, II, § 3ª, ele deverá prestar serviços a comunidade por 5 (cinco) meses.

2) KAIQUE:

Fixo a pena base no mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Isto porque, a meu sentir, não há razões para que a pena base seja aumentada além do mínimo já que o tipo de entorpecente apreendido em posse dele bem como a quantidade, não desbordam do que ordinariamente já está previsto no tipo penal. Portanto, quanto a este aspecto, discordo da posição trazida pelo Ministério Público.

Em segunda fase, a confissão não será utilizada para o fim de se diminuir a pena aquém do mínimo legal.

Em terceira fase, pesem as ponderações trazidas pelo Ministério Público, entendo que é o caso de aplicação do tráfico privilegiado, ou seja, a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006. O réu é primário e não possui Maus antecedentes, fls.78. Não se pode presumir, de outra banda, que ele se dedicava à atividade criminosa de forma habitual ou, ainda, que integrasse organização criminosa. Só é viável o afastamento da benesse se a condição de reincidente ou portador de Maus antecedentes, bem como de integrante de organização criminosa ou delinquente habitual, restarem devidamente comprovadas. Não basta que tenha sido preso em flagrante por tráfico para se atribuir ao réu a prática de atividades criminosas que impeçam a redução da pena. É necessário que dos autos, ou das circunstâncias da prisão, sobressaiam elementos indicativos de outras atividades ilícitas que não o próprio tráfico em si. Contudo, em atenção ao que determina o artigo 42 da Lei de Drogas, entendo que a dedicação do acusado ao cultivo da planta bem como a quantidade de planta arbustiva apreendida em seu poder, com expectativa de razoável produção de entorpecente com maior teor de THC, a carga redutora a ser aplicada, considerando-se as circunstâncias do caso concreto, é de 1/4 (um Quarto).

Assim sendo, diminuo a pena anteriormente aplicada em 1/4 (um quarto), com o que a reprimenda privativa de liberdade resulta em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa.

Ausentes outras causas modificadoras da pena, torno definitiva a sanção acima estabelecida. Fixo o regime aberto para início de cumprimento da pena pois entendo ser suficiente a, no caso concreto, coibir a prática delitiva.

Por fim, estabeleço o regime aberto para cumprimento da reprimenda. Isto porque, apesar de o art. 2º, §1º da Lei nº 8.072/90 determinar a fixação de regime inicial fechado para cumprimento do delito de tráfico de entorpecentes, por equipará-lo a hediondo, esta previsão não se aplica ao tráfico privilegiado. Como cediço, em decisão recente, o Supremo Tribunal Federal assentou entendimento no sentido de que o delito de tráfico de drogas, quando há o reconhecimento do privilégio previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, não é equiparado a hediondo, nos termos da Lei nº 8.072/90, conforme se depreende do teor da seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES

PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos. 2. O tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de Maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa. 3. Há evidente constrangimento ilegal ao se estipular ao tráfico de entorpecentes privilegiado os rigores da Lei n. 8.072/90. 4. Ordem

concedida" (Habeas Corpus nº 118.533/MS - Tribunal Pleno- Rel. Min. Cármen Lúcia - j. 23.06.2016).

No mesmo sentido, os recentes Habeas Corpus nº 136.545, de relatoria do Min. Celso de Mello, j. 07.10.2016; nº 136.762, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, j. 06.10.2016; e Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 937.651, de relatoria do Min. Roberto Barroso, j. 09.09.2016.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação e o faço para:

1) DESCLASSIFICAR a conduta atribuída a GABRIEL DE MORAES BRAGA, RG: 53443444, CPF: 467.603.498-90, nascido em 03/03/1997, filho de Renan de Melo Braga e Juliana Simões de Moraes para o artigo 28 da Lei 11.343/2006 e determinar, nos termos do artigo 28, II, § 3ª, do Diploma Legal mencionado, que ele preste serviços a comunidade por 5 (cinco) meses.

2) CONDENAR KAIQUE DE MORAES BRAGA, RG: 39539869, CPF: 494.634.088-27, nascido em 27/09/1999, filho de Renan de Melo Braga e Juliana Simões de Moraes, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 33, "caput" e § 4º da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, REGIME ABERTO, e pagamento de 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa e corrigidos desde a data do fato.

Outrossim, não há que se falar em conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos. Ainda que haja entendimento jurisprudencial em sentido contrário e mesmo que nos autos do Habeas Corpus nº 97.256, a expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" tenha sido incidentalmente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, sendo promulgada a Resolução nº 05/2012 pelo Senado Federal, mantenho meu entendimento no sentido da impossibilidade da referida conversão.

Com efeito, inviável a fixação de penas restritivas aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, em qualquer de suas modalidades, havendo ou não aplicação do redutor de pena previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, até porque a conversão das penas privativas de liberdade não é automática, devendo o Magistrado analisar os preceitos estabelecidos do Código Penal.

No presente caso, temos que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ao réu, que claramente praticava o comércio de drogas é insuficiente para a prevenção e repressão do delito, sendo, portanto, sua concessão, vedada pelo art. 44, inciso III, e 77, II, ambos do Código Penal.

Cumram-se as Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo.

Transitada em julgado, determino as providências: 1) Em observância ao item 22, "d", do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD; 2) Lance-se o nome dos sentenciados no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 393, II, do CPP, c.c art. 5º, LVII, da Constituição Federal; 3) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal;

Transitada esta em julgado tornem conclusos para a designação de data para audiência admonitória em relação a Kaique, expedindo-se o que for necessário para o cumprimento da prestação de serviços a comunidade por parte de Gabriel.

Consequentemente, concedo a ambos o apelo em liberdade.

Expeçam-se Alvarás de Soltura Clausulado.

Isento de custas. Publicada em Audiência,

São Paulo, 01/09/2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA